

1500078-55.2022.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... imputar ao denunciado a prática do crime de tráfico. Alternativamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado na forma do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, fixação de regime aberto e que diante da primariedade e bons antecedentes o réu deve ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-55.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-55.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048682/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 23131139 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 134/22/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2048682 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 134/22/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FRANQUES PEIXOTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Bruno Franques Peixoto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, eis que no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 13h00, na Avenida Maria Aparecida Salgado Braghetta, Vila Maschietto, no local conhecido como "biqueira do buracão", nesta cidade e comarca, Bruno, trazia consigo, para fins de tráfico, 105 (cento e cinco) pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 45 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Liberdade Provisória concedida (págs. 84/88).

A denúncia de págs. 111/113 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/24.

O réu foi citado (pág. 140) e apresentou defesa preliminar (págs. 141/142), alegando provar sua inocência no transcorrer da instrução processual.

A denúncia foi recebida aos 15 de junho de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 147/149).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada em Cartório e disponível aos interessados. A audiência de instrução foi realizada aos 16 de agosto de 2022 e também no dia 01º de setembro de 2022 - pgs. 182/187, em continuação.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, pois a versão do réu não é convincente ao passo que nada desabona as palavras dos policiais. Requer o aumento da pena base diante da quantidade de droga apreendida. Por outro lado, não indica agravantes ou atenuantes e concorda com a concessão do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, concedendo o regime aberto ao réu - pgs. 194/198.

A defesa, por sua vez, manifestou-se nas pgs. 202/207 alegando que diante da insuficiência de provas não há como imputar ao denunciado a prática do crime de tráfico. Alternativamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado na forma do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, fixação de regime aberto e que diante da primariedade e bons antecedentes o réu deve ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (págs. 06/08), auto de exibição e apreensão que acompanha o flagrante (págs. 09/10); Auto de Constatação Preliminar (pág. 11) e exame químico-toxicológico de pgs. 123/125.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Rivaldo Luciano Tonhão relata que o local é o "buracão", ponto de intensa traficância de crack. Entrou com sua moto e verificou o réu, vulgo Stallone, fazendo contato com um indivíduo. Ele dispensou um invólucro plástico e foi abordado, porém resistiu. Houve necessidade de força física. Ele disse que era usuário. Ele foi visto diversas vezes no local. Viu o réu numa transação. Chegaram e viram isso em patrulhamento. Ele era visto bastante lá e continua sendo visto no mesmo local, com denúncias de estar traficando de novo. Ele não sai do local. Desconhece se ele trabalha ou tenha alguma atividade lícita. Pelo que sabe não há outros membros da família dele envolvidos com tráfico. Há denúncias encaminhadas diretamente ao depoente de que o Stallone continua no local, traficando. Já viu o réu no local, na parte da tarde, em dias de semana. 105 pedras de crack está um pouco acima da quantidade corriqueira de pedras de crack que são apreendidas aqui. O outro rapaz não foi abordado, ele correu. Também não foi identificado. Viu ele dispensado a droga. Não conhece as testemunhas de defesa e eles não estavam no local da abordagem. O réu foi abordado em local distante da ocorrência, em virtude da fuga.

João Paulo Gonçalves Parra reafirma que o local é conhecido dos meios policiais por intenso tráfico de drogas, sendo o crack o "carro chefe" dali. O réu viu a viatura e saiu correndo, dispensando um invólucro. Ele resistiu à abordagem. O réu estava próximo a uma outra pessoa, bem próxima. O outro indivíduo ficou parado, mas o réu correu. Foram atrás dele e quando voltaram o outro indivíduo não estava mais. Ele disse que era usuário. Depois dos fatos já tiveram outras denúncias de que ele continua traficando ali. O vulgo dele é Stallone. Viu ele dispensando o invólucro e não tem dúvidas. 105 pedras considera quantidade grande. Ele é frequentemente visto lá, durante a semana, à noite, durante sábado e domingo. Ele tem sido visto em dias normais de semana. Desconhece se ele trabalha. Desconhece as testemunhas de defesa. O réu foi abordado perto da rotatória, distante no máximo 1 km do local da ocorrência. O réu foi preso próximo a um depósito de bebidas. No momento, estavam tentando algemar, fazer busca pessoal e não sabem se havia outras pessoas ao redor. Marcelo Pureza da Silva informa que viu a polícia abordando o réu nas proximidades do bar do Nenê, mas não viu o réu dispensado nada. Foi comprar um cigarro no bar ali e viu o pessoal das motos abordando ele. Não deu para ouvir o que eles estavam conversando. Conhece o Bruno porque jogavam futebol, mas só de vista. Não sabe onde o réu mora. Não sabe o que ele estava fazendo na biqueira. Não sabe se ele usa droga.

Juliana de Cássia Carvalho disse que estava indo na rua Miosótis e o réu estava virando a esquina e duas motos vieram e abordaram ele, em seguida, revistaram ele e tudo. Viu apenas achando dinheiro. Não conseguiu ouvir o que eles disseram. Não viu a polícia achando a droga. Não conhece o réu. Ele mora próximo no bairro, mas a depoente não mora mais lá.

O acusado, Bruno Franques Peixoto, nunca foi preso. Trabalha de servente com seu pai. Estudou até o primeiro colegial. É casado e tem uma filha de cinco meses e uma filho de cinco anos. Tem 26 anos. Usa crack e maconha. Nunca foi internado. A droga não lhe pertence. No dia do ocorrido, foi lá fumar. De vez em quando, tem problemas na vida, desanima e fuma crack. Fuma 1 vez por semana. Trabalha também e foi fumar. Chegou no buracão e estava com 4 rapazes. Estava usando a droga. Tinha acabado de fumar no cachimbo. Assustou e saiu correndo. A outra ROCAM subiu lá na frente e o depoente foi no sentido de um depósito. Eles mandaram colocar a mão na cabeça e depois para trás. O Rivaldo chegou e derrubou o depoente e disse que estava preso. Ele pegou R\$ 198,00 do seu bolso. Ele falou que na delegacia o depoente ia ver porque estava preso. Levaram o depoente no pronto socorro. Apertaram muito sem braço e sua perna que sangrou. O médico falou que ia colocar isso no laudo. Não estava conseguindo nem andar. Sua mulher perguntou ao policial o motivo da prisão e ele mandou ela "tomar no cu". Não tem apelido de Stallone não, mas já teve. Nunca teve problema com os policiais. Eles lhe enquadravam e ficavam jogando "piadinhas" no ar para o depoente. Na cadeia o Rivaldo falou que sabia que o depoente iria

sair, mas que iria pegá-lo depois e ia quebrá-lo e deixá-lo ensanguentado. Não dispensou nada em nenhum momento. Não viu ninguém dispensando nada, correu um para cada lado. Nada mais tem a declarar. O dinheiro tinha recebido do seu pai que lhe paga semanalmente. O dinheiro não estava picado. Havia 2 notas de R\$ 50,00 e o restante era de R\$ 20,00. Era 4 notas de R\$ 20,00, 2 de R\$ 10,00. Não sabe sobre as outras notas. Não tinha notas picadas não. Tinha consigo R\$ 200,00 e estava lá usando droga sozinho. Comprou de um rapaz, mas não conhece ele.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR

AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

A bem da verdade, os policiais realizavam patrulhamento de motocicleta especializado na Av. Perimetral, no bairro Vila Maschietto, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas (denominado pelos usuários como "biqueira do buracão").

Explicam que desceram com suas motocicletas por um lado do bairro, deparando-se com Bruno, que estava aparentemente negociando algo com outro rapaz. Ato contínuo, ao perceber a presença da motocicleta dos Polícias Militares, Bruno tentou se evadir. Ante a fundada suspeita, abordaram o indiciado Bruno, e, em seguida, foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado com ele o valor de R\$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) dividido em 24 notas de R\$ 2,00, 6 notas de R\$ 5,00, 4 notas de R\$ 10,00 e 4 notas de R\$ 20,00. Ato contínuo, os policiais foram até o local onde momentos antes Bruno havia arremessado invólucro plástico, logrando êxito em encontrarem 105 "pedras" da droga vulgarmente conhecida como crack.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 105 "pedras" de crack para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafeto ou problema pessoal. Cabe ponderar, ainda, que ambos os policiais empenhados na diligência são experientes e sabem perfeitamente diferenciar atos de mero uso ou compartilhamento de drogas de atos de entrega ao consumo de terceiro, venda/mercancia ilícita de crack, tal como ocorre frequentemente na biqueira do "Buracão".

No que tange à alegada drogadição do réu, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figura do viciado-traficante" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Em relação aos argumentos defensivos de insuficiência de provas tem-se que o artigo 156 do CPP é claro: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:"

Com efeito, a dúvida capaz de favorecer o réu deveria estar sustentada em

contraprovas e não meramente a partir de argumentações, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o "decisionismo". As contraprovas incumbem à defesa, na exata dicção do art. 156 do CPP.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

A verdade processual obtida vem no sentido de que as acusações ministeriais estão evidenciadas no laudo de exame químico-toxicológico e depoimentos dos policiais empenhados na diligência.

Portanto, este Juízo não se ressentido de dúvida razoável capaz de direcionar sua convicção em sentido oposto à tese constante na denúncia.

Em suma, o caso sub examen evidencia a prática de crime diverso do simples porte para uso exclusivo e pessoal de entorpecentes. Revela, na verdade, manutenção de drogas para entrega também a terceiros, ficando afastada a possibilidade de desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 111/113 para CONDENAR BRUNO FRANQUES PEIXOTO pela prática do crime capitulado no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o *modus operandi* não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

O réu é primário (págs. 25).

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois

a apreensão foi de 14,58 gramas - massa líquida indicada no exame químico-toxicológico de pgs. 124.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo não encontra campo para acréscimo, pois não há quantidade-variedade de drogas diferentes e a quantidade de crack, apenas 14,58 gramas, não pode ser considerada acima daquelas encontradas em apreensões corriqueiras nesta comarca.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não recomendam o acréscimo da pena base.

Não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, em 5 anos de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o réu é primário e a quantidade de entorpecentes não é suficiente para indicar ligação a organização criminosa.

Portanto, considerando que o réu é primário e a apreensão não possui dimensão suficiente para indicar que o réu integra organização criminosa deve ser beneficiado com o redutor em seu patamar máximo.

Deste modo, reduzo a pena em 2/3 fixando-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33,

que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

Evidentemente que as instâncias ordinárias deverão observar se o entendimento se firmará e quais serão seus demais contornos e reflexos. Ressalvo, ainda, meu posicionamento pessoal sobre a maior adequação do regime inicial fechado para os casos de tráfico de entorpecente, que se sustentava, entretanto, também em sua equiparação a crime hediondo.

Em matéria disponível no site "Conjur", divulgada em 2016, verifica-se que novamente o E. STF entendeu pela impossibilidade de fixação do regime fechado aos casos de tráfico privilegiado. As decisões são do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli e foram proferidas em dois pedidos de HC impetrados pelo defensor público Alexandre Orsi Netto, que atua em Sorocaba.

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

No Habeas Corpus nº 457.359/SP (2018/0162657-9), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 23.08.2018 o E. STJ reafirmou a mudança de posicionamento quanto ao tema por parte da Quinta e Sexta Turmas daquela Corte Superior, que culminou na revisão do entendimento anteriormente consolidado, pela Terceira Seção, e no cancelamento do Enunciado nº 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

A este respeito também é devida observância à súmula 440 do STJ, bem como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do regime, ou ainda o teor da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal.

Eis o teor das súmulas citadas:

SÚMULA Nº 440 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

SÚMULA Nº 718 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

SÚMULA Nº 719 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Com tais fundamentos, fixo o regime ABERTO, considerando os precedentes supra, primariedade do réu e pequena quantidade de droga apreendida.

Inviável, no entanto, a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 - SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 - SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição

citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que "se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa - e com maior razão."

Em meu entendimento, não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestar serviços comunitários.

Ademais, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Fica suspensa a cobrança na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c/c art. 3º do CPP, pois o réu está patrocinado por advogado dativo.

Honorário na forma do convênio OAB-DPE. Expeça-se certidão, na ordem dos serviços.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão observando o regime fixado. Faculta-se ao réu apresentar-se em Juízo no horário das 13:00 às 16:30 durante os dias úteis, ocasião em que sua audiência admonitória será "encaixada" na pauta regular, evitando-se o cumprimento de mandado de prisão em regime aberto pela Polícia a fim de prevenir eventuais intempéries que excepcionalmente podem ocorrer em situações análogas; Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado

para as anotações necessárias;

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois ausente comprovação de sua origem lícita, conclui-se que trata-se de proveito da traficância desenvolvida, especialmente diante das circunstâncias da apreensão em conhecida "biqueira" de drogas local e pelo fracionamento das notas, típico de vendas de pedras de crack no varejo.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA